

1534940-97.2019.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: FABIOLA OLIVEIRA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/10/2022

... de elementos que indicassem o tráfico. No mérito, pugnou a absolvição por falta de provas.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é improcedente.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/06), auto de exibição e apreensão (fls. 07/08), laudo pericial (fls. 38/40), bem como pela prova oral.

A ação penal é ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, Rua 04 1º Piso Salas 1-220 e 1-221, Barra Funda -

CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9031, São Paulo-SP - E-mail: Sp16cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1534940-97.2019.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1534940-97.2019.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Fato Atípico

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS CORDEIRO DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIOLA OLIVEIRA SILVA

Vistos.

DOUGLAS CORDEIRO DA SILVA e KENNYD PEREIRA PIRES, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 29, caput, do Código Penal, porque, no dia 26 de janeiro de 2019, por volta da 00h30, nas dependências da estação de metrô República, República, nesta cidade e comarca de São Paulo, Capital, traziam consigo e guardavam, para entrega a terceiros, 06 (seis) frascos plásticos contendo CLORETO DE METILENO/DICLOROMETANO, substância popularmente conhecida como "lança-perfume", periciados como dois itens, o primeiro com volume líquido total de 145ml (cento e quarenta e cinco mililitros) e o segundo com 1600ml (mil e seiscentos mililitros), em desacordo e sem autorização legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida (fls. 59/60), os réus foram citados e apresentaram defesa prévia (fls. 113/114).

Mantida a decisão que recebeu a denúncia (fl. 115), a testemunha não foi encontrada, tendo o Ministério Público desistido da oitiva ante a não localização. Sem oposição pela defesa, a desistência foi homologada. Decretada a revelia do acusado Kenedy, pois intimado, não compareceu à audiência.

Nos debates, o Ministério Público pleiteou a parcial procedência, condenando-se o acusado pelo crime de posse para consumo pessoal.

A d. Defesa, por sua vez, requereu preliminarmente a inépcia da denúncia tanto pela busca pessoal como pela inexistência de elementos que indicassem o tráfico. No mérito, pugnou a absolvição por falta de provas.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A ação penal é improcedente.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/06), auto de exibição e apreensão (fls. 07/08), laudo pericial (fls. 38/40), bem como pela prova oral.

A ação penal é improcedente.

Afasto a preliminar levantada pela defesa, vez que a denúncia menciona o uso das drogas para consumo pessoal ao referir às versões apresentadas pelos acusados. Outrossim, a quantidade de drogas apreendidas, a depender do conjunto probatório, podem demonstrar o destino de tráfico.

Afasto a sustentada nulidade da busca pessoal realizada pelos metroviários. Importante destacar o exercício do poder de polícia dos agentes, outrossim, a existência de indicativos relativos à ocorrência de crime, consistente na informação dos usuários, os quais solicitaram o comparecimento, anunciando que grupo de pessoas consumia drogas no local. Assim, compareceram e, ante tais indicativos, realizaram abordagem. No sentido de que não há impedimento à realização da busca cito decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça: AgRg no HABEAS CORPUS Nº 597.923 - SP (2020/0176108-4), MINISTRO NEFI CORDEIRO.

No mais, não foram ouvidas testemunhas na fase judicial, apesar de designadas duas audiências para tanto. O acusado, a seu turno, permaneceu em silêncio.

Após o encerramento da breve instrução criminal, não se verifica prova judicial mínima necessária para condenação do acusado. Há de se notar que todos os indícios trazidos para a instrução criminal provém de oitivas realizadas na fase policial, inexistindo qualquer prova judicial apta a confirmar a materialidade do delito ou conferir certeza da autoria.

Observando-se o teor do depoimento da vítima na fase do inquérito, denota-se que os indícios de autoria que apontavam para o acusado e que levaram ao recebimento da denúncia, não se jurisidicionalizaram, posto que, em Juízo, não houve sua confirmação cabal.

A impossibilidade de condenação embasada em indícios colhidos exclusivamente no inquérito policial é pacífica na Doutrina e Jurisprudência, estando acobertada por uma das razões fundantes de existência do processo penal, que é a de produção de provas em juízo e mediante o exercício do contraditório pelas partes.

Anota-se ainda que não se trata somente de entendimento ou criação intelectual, mas de aplicação literal da disposição contida no artigo 155 do Código de Processo Penal, cuja redação foi definida com a reforma promovida pela Lei 11.690/2008: "O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. ".

Veja-se que no caso em tela não há de se falar em qualquer prova cautelar ou antecipada produzida durante o inquérito. Ao contrário, as oitivas realizadas tem natureza jurídica de meros indícios, pois produzidas sem o crivo do contraditório e presididas por autoridade policial. Tal posicionamento vem traduzido nos excertos doutrinários a seguir:

Em síntese, o CPP não atribui nenhuma presunção de veracidade aos atos do IP. Todo o contrário, atendendo a sua natureza jurídica e estrutura, esses atos praticados e os elementos obtidos na fase pré-processual servem para justificar o recebimento ou não da acusação.

É patente a função endoprocedimental dos atos de investigação. Na sentença, só podem ser valorados os atos praticados no curso do processo penal, com plena observância de todas as garantias. LOPES Jr, Aury. Direito processual penal. Aury Lopes Junior. - 17. ed. - São Paulo : Saraiva Educação, 2020. p. 272/273. (grifo nosso)

O inquérito policial não é um processo, mas simples procedimento. A polícia investiga o crime para que o Estado possa ingressar em juízo, e não para resolver uma lide, dando a cada um o que é seu. Donde ter dito Birkmeyer que, na fase policial, o réu é simples objeto de um procedimento administrativo, e não sujeito de um processo jurisprudencialmente garantido. HELENO FRAGOSO, Jurisprudência Criminal, nºs 101 e 102. (grifo nosso).

Sendo na Jurisprudência dos Tribunais Superiores é esta também a linha seguida: Somente a prova penal produzida em juízo pelo órgão da acusação penal, sob a égide da garantia constitucional do contraditório, pode revestir-se de eficácia jurídica bastante para legitimar a prolação de um decreto condenatório. (HC 73.338/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO.

Habeas corpus: falta de justa causa: inteligência. 1. A previsão legal de cabimento de habeas corpus quando não houver "justa causa" para a coação alcança tanto a instauração de processo penal, quanto, com maior razão, a condenação, sob pena de contrariar a Constituição. 2. Padece de falta de justa causa a condenação que se funde exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial.

II. Garantia do contraditório: inteligência. Ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em testemunhos prestados no inquérito policial, sob o pretexto de não se haver provado, em juízo, que tivessem sido obtidos mediante coação (STF, Primeira Turma, RE 287658/MG , rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 16/09/2003.

O inquérito policial não pode ser sede de sentença condenatória, porquanto a prova testemunhal que nele se acolheu só adquire valor jurídico através de sua jurisdicionalização, que só acontece no sumário. Logicamente, se a prova só se produz não estando a denúncia provada na instrução criminal, a condenação só será possível negando-se vigência ao art. 386, VI do Código de Processo Penal (RTJ 59/789). HC 69.904. Rel. Min. BARROS MONTEIRO.

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO EMBASADO EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS

COLHIDOS DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL. OFENSA À GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Em respeito à garantia constitucional do devido processo legal, a legitimidade do poder-dever do Estado aplicar a sanção prevista em lei ao acusado da prática de determinada infração penal deve ser exercida por meio da ação penal, no seio da qual ser-lhe-á assegurada a ampla defesa e o contraditório. 2. Visando afastar eventuais arbitrariedades, a doutrina e a jurisprudência pátrias já repudiavam a condenação baseada exclusivamente em elementos de prova colhidos no inquérito policial. 3. Tal vedação foi abarcada pelo legislador ordinário com a alteração da redação do artigo 155 do Código de Processo Penal, por meio da Lei n. 11.690/2008, o qual prevê a proibição da condenação fundada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. 4. Constatado que o Tribunal de origem utilizou-se unicamente de elementos informativos colhidos no inquérito policial para embasar o édito condenatório em desfavor da paciente, imperioso o reconhecimento da ofensa à garantia constitucional ao devido processo legal. REPRIMENDA. REGIME DE EXECUÇÃO. MODO FECHADO DETERMINADO COM BASE NA GRAVIDADE EM ABSTRATO DO DELITO. DESCABIMENTO. PENABASE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGALMENTE PREVISTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. ART. 33, §§ 2º E 3º DO CÓDIGO PENAL. SÚMULAS 718 E 719 DA SUPREMA CORTE. COAÇÃO ILEGAL EVIDENCIADA. ALTERAÇÃO PARA O MODO SEMIABERTO. 1. O art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal estabelece que o condenado à pena superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) poderá iniciar o cumprimento da reprimenda no regime semiaberto, observando-se os critérios do art. 59 do aludido diploma legal. 2. Fixada a pena-base no mínimo legal e sendo o acusado primário e sem antecedentes criminais, não se justifica a imposição do regime prisional mais gravoso. 3. A Suprema Corte, nos verbetes 718 e 719, sumulou o entendimento de que a opinião do julgador acerca da gravidade genérica do delito não constitui motivação idônea a embasar o encarceramento mais severo do sentenciado. 4. Ordem concedida para cassar o acórdão objurgado apenas com relação à paciente Márcia Regina Pereira, restabelecendo-se a sentença absolutória proferida pelo magistrado singular, com a determinação de expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver presa e para estabelecer o regime semiaberto como modo inicial de cumprimento da sanção aplicada ao paciente Adriano Emílio Marchesini. (STJ, Quinta Turma, HC 200802252070, rel. Min. Jorge Mussi, 14/02/2011).

Desta forma, inexistindo qualquer prova judicial e tendo dela desistido a acusação, há de se fazer valer o princípio basilar da presunção de inocência da acusada.

Dispositivo.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal, a fim de ABSOLVER os acusados DOUGLAS CORDEIRO DA SILVA e KENNYD PEREIRA PIRES, qualificados nos autos, como incursos nos artigos artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 29, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Os réus poderão recorrer em liberdade.

Feitas as anotações de praxe, arquivem-se.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes.

São Paulo, 17 de outubro de 2022.